InDret Penal

# *Prevaricación y tensiones sustantivo-procesales*

¿Prevarica un juez que dicta a sabiendas una sentencia que resulta materialmente –sustantivamente- injusta, cuando ello le viene impuesto (o, al menos, está permitido) por una regla o principio procesal: por ejemplo, el principio acusatorio?

Las respuestas podrían ser, de entrada, radicalmente extremas: sí, porque la justicia sustantiva no puede someterse a condicionante alguno; o no, porque el sistema penal ha de ser armónico y no puede existir una justicia sustantiva descontextualizada del marco de garantías procesales. Ahora bien, el sistema procesal penal Español, que contiene la excepción del art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hace que la respuesta resulte algo más compleja. Veámoslo de la mano de un ejemplo. La SAP Vizcaya (secc. 1ª) de 23 de abril de 2009 (ponente González González) hubo de examinar, entre otros, el siguiente hecho probado. Francisca había sometido a Almudena (hija de una unión anterior de su marido Eleuterio) a reiterados actos de maltrato físico y psicológico, prolongados durante años e intensificados en los meses anteriores al día 14 de diciembre de 2005. Ese día "*Francisca recriminó a Almudena* (que contaba once años de edad: JMSS) *por un problema con las notas, en concreto, un suspenso que había tenido en una asignatura y que había ocultado, dirigiéndole expresiones despreciativas y golpeándola en la cara y en la cabeza. Por la tarde, al regresar del colegio, Francisca la dejó desnuda en el cuarto de baño y después la obligó a permanecer encerrada en su habitación. Cuando la niña pidió ser perdonada, con la intención de que se quitara la vida y de esa manera solucionar lo que para ella en ese momento percibía como un problema, le dijo que se tirase por la ventana y también le indicó a los otros hermanos que le dijeran lo mismo. Almudena regresó a su habitación y escribió una nota de suicidio, que entregó a Francisca quien la rompió diciéndole que tenía que escribir otra, lo que Almudena hizo siguiendo las indicaciones de Francisca, quien le recalcó que no valía para nada y que lo mejor para toda la familia es que se tirara por la ventana. La niña insistió, pidiendo perdón, y diciendo que 'para vivir así me quiero morir'. Francisca y los hermanos, por indicación suya, le negaron el perdón e incluso le volvieron la cara cuando Almudena pretendió besarles, insistiendo en que se fuera a su habitación y que se tirara por la ventana.*

*Como consecuencia de la presión ejercida y de la situación de desesperación a la que había sido conducida, Almudena regresó a su habitación y se precipitó desde la ventana hasta la calle...*" aunque no llegó a morir sino que sufrió graves lesiones.

La Sala advirtió la -manifiestamente correcta- posibilidad de calificación del hecho como autoría mediata (de homicidio intentado y de lesiones consumadas). Pero, añadió que "*sin embargo dicho debate queda excluido en el caso concreto por exigencias del principio acusatorio al haberse limitado la acción penal a la concurrencia de un delito de inducción al suicidio*".

Resulta obvio que el Fiscal sufrió un gravísimo error que condujo a la imposición de una pena inferior en muchos años a la merecida por Francisca. Ahora bien, ¿obró correctamente la Sala? ¿No se puede hablar aquí de una prevaricación, ni siquiera imprudente?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 733[1], establece lo siguiente, bajo el título de "*Planteamiento de la tesis por el Tribunal*":

"Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente fórmula:

«Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fuesen varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de... o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el núm. ... del artículo... del Código Penal».

Esta facultad excepcional, de que el Tribunal usará con moderación, no se extiende a las causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a los errores que hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto a la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes, como en cuanto a la participación de cada uno de los procesados en la ejecución del delito público que sea materia de juicio.

Si el Fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicaren que no están suficientemente preparados para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se suspenderá la sesión hasta el día siguiente".

La figura definida en el artículo reproducido provoca cierta perplejidad. En efecto, de su lectura parece desprenderse que cabe que el Tribunal advierta un error manifiesto en la calificación jurídica de los hechos por parte de la acusación y defensa y que, ello no obstante, no haga nada y aplique conscientemente el Derecho de modo erróneo. Y ello sería lícito. Claro que también cabe que haga algo y proponga ser ilustrado acerca de otras posibles calificaciones. Pero esa facultad (¡no deber!) de la que se indica que debe ser utilizada de modo excepcional (por comprometer en cierta medida la pasividad imparcial con que el Tribunal ha de contemplar el objeto del proceso) puede no ser secundada por las partes [2]. ¿Qué ocurre entonces?

Las muy diversas tomas de posición existentes en la doctrina procesal penal prácticamente agotan todas las posibilidades. Un grupo de autores sostienen que, pese al tenor de la ley, el planteamiento de la "tesis" es un deber del tribunal (así, *Asencio Mellado*). Lo que significaría que el juez que no plantea la tesis puede incurrir en prevaricación. Pero, a partir de ahí, cabe que las partes acojan la invitación a ilustrar al tribunal o no. Pues bien un sector admite entonces la posibilidad de condenar conforme a la tesis aunque las partes

---

[1] Que se relaciona con el art. 851, 4º LECrim.

[2] Cfr. DE LA OLIVA, en DE LA OLIVA y OTROS, *Derecho procesal penal*, 1993, Madrid, pp. 510 y ss., insistiendo en que la tesis no es acusación y en que con ella se pretende armonizar el concepto de acusación y el Derecho penal, señalando que no se puede aceptar un "poder sobre el Derecho".

acusadoras no la hayan hecho suya (por ejemplo, *Moreno Catena*). Claro que si sólo se trata de una posibilidad, entonces no cabría condenar por prevaricación si tal cosa no se hiciera. El Tribunal Supremo, por su parte, se mantiene en que se trata de una facultad. Y en que, una vez planteada, sólo cabe condenar conforme a la tesis en caso de asunción por una de las partes acusadores y no si dicha tesis no es asumida por nadie[3]. Por tanto, no habría prevaricación ni por dejar de plantear la tesis ni, habiéndola planteado, por dejar de condenar si las partes no han hecho suya la calificación propuesta. En fin, *López Barja de Quiroga* entiende que la cláusula del art. 733 LECrim es inconstitucional en todo caso por violar el principio acusatorio[4]. Luego, *a fortiori*, excluye la posibilidad de calificar la conducta judicial como prevaricadora cuando deja, a sabiendas, de condenar por el tipo materialmente adecuado, siendo así que dicha calificación no fue sostenida por ninguna de las acusaciones.

Paradojas de la relación entre el Derecho penal sustantivo y el Derecho procesal penal. Que sin embargo no carecen de consecuencias importantes, tanto en el plano práctico como en el estrictamente teórico. Expresémoslo mediante cinco enunciados. *Primero:* Ante un error manifiesto de la acusación, el planteamiento de la tesis es una pura facultad, que las partes acusadoras pueden seguir o no; y, en el caso de que no la sigan, el Tribunal no puede acoger la calificación planteada. *Segundo:* Así las cosas, la injusticia de la resolución, a los efectos del delito de prevaricación requiere una injusticia no sólo sustantiva, sino también procesal. *Tercero:* Por tanto, la norma primaria (o norma de conducta) del delito de prevaricación judicial –que es la cláusula de cierre del sistema de normas de conducta jurídico-penales- se integra de elementos procesales, además de los sustantivos. *Cuarto:* Luego las normas secundarias jurídico-penales integran, de modo general, los referidos elementos procesales. *Quinto*: Lo anterior conlleva que el hecho delictivo, en tanto que *hecho realmente punible* (esto es, punible por un juez del mundo real), incorpore el requisito de poder y deber ser procesalmente punible.

Jesús-María Silva Sánchez

---

[3] Sobre las diversas posiciones, MARTÍNEZ ARRIETA, "Principio acusatorio: Teoría general y aplicación práctica", en *Cuadernos de Derecho Judicial. Los principios del proceso penal*, 1992, Madrid, pp. 51 y ss., 75 y ss.

[4] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Tratado de Derecho procesal penal*, 2ª ed., 2007, Navarra, pp. 115 y ss., 119, 1219.